

1510709-20.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... si só, não é suficiente a caracterizar o crime de tráfico. No entanto, o montante e variedade de drogas apreendidas em poder do réu, não deixam dúvidas que serviam para o tráfico de drogas, eis que a quantidade apreendida, na circunstância, mostra-se absolutamente incompatível com o uso próprio.

Além disso, as demais circunstâncias dos autos, tais como, a atitude suspeita ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1510709-20.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510709-20.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2120731/2020 - 69º Distrito Policial - Teotônio Vilela, 2707/2020 - 69º Distrito Policial - Teotônio Vilela

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON BATISTA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Processo nº 671/20

VISTOS.

JEFFERSON BATISTA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas 33, caput, da Lei 11.343/06 porque consta que no dia 16 de maio de 2020, às 17:15 horas, em ocasião de calamidade pública, na Rua Vitotoma Mastroirosa, nº 433, São Mateus, nesta Capital, guardava, para fins de tráfico, sem autorização legal, 92,5g de maconha, 52,8g de cocaína, e 12,6g de cocaína em forma de crack, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica.

A denúncia foi recebida a fls. 83.

Defesa preliminar a fls. 101/119.

Durante a instrução processual, foram ouvidas, através do sistema de áudio e vídeo, quatro testemunhas e o réu foi interrogado.

Em debates, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia por entender bem demonstradas autoria e materialidade do crime. Pediu ainda a extração de cópias dos autos para processamento da testemunha

Mauricio de Oliveira, por falso testemunho.

A defesa, por seu turno, em memoriais a fls. 231/249, requereu a absolvição do réu pela ausência de provas suficientes para condenação. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da minorante prevista no §4º do artigo 33, com pena mínima, regime mais brando, conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a possibilidade de o réu apelar em liberdade.

É o relatório.

DECIDO.

Afasto de plano a preliminar arguida pela Defesa do réu, uma vez que a presente ação penal transcorreu de forma legal e regular, nada havendo nos autos, capaz de maculá-la de vício insanável.

A denúncia descreveu os fatos de forma clara e objetiva, tanto que possibilitou ao Douto Defensor, a elaboração de completa defesa.

Com efeito, não há que se falar em nulidade da prisão em flagrante em decorrência de prova ilícita. Fato é que os policiais localizaram grande quantidade de drogas em poder do réu, fato que por si só, já é suficiente a legitimar a ação dos policiais.

Não se ignora os preceitos constitucionais trazidos a baila pela Defesa, segundo os quais a casa é asilo inviolável, a menos que no interior dela esteja ocorrendo um crime, momento em que, a prisão em flagrante mostra-se absolutamente regular, legal e até mesmo necessária.

Superada a questão, a presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva veio bem comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12, dando conta das 60 porções de maconha, das 40 porções de cocaína, das 131 pedras de crack, além dos R\$ 55,75, localizados e apreendidos em poder do réu.

Em complementação, o Exame Químico Toxicológico de fls. 198/200, atestou que as substâncias apreendidas eram positivas para cocaína e tetrahidrocannabinol.

A autoria também é inconteste.

Os argumentos da Douta Defesa Técnica não arredaram os fortes indícios e provas diretas que derivaram contra o réu, em especial, pelos laudos periciais, testemunhas inquiridas e declaração do próprio acusado, que nada de exculpatório trouxe aos autos.

Na Delegacia de Polícia, o réu negou o tráfico alegando que estava em frente a sua residência quando foi abordado pelos policiais e não estava traficando, fls. 08. Em juízo declarou que no dia em questão, eu estava no portão de casa sentado na calçada, eu Maurício, a Elizabel e Amanda. Eu estava tomando bebida alcoólica. Aí passou uma viatura, aí teve uma gracinha com leite, alguma coisa parecida, a viatura voltou e fez abordagem. Eles entraram num corredor, eu morava numa viela, acharam a droga. Adentraram na minha casa sem minha permissão, bagunçaram tudo, me pegaram e autuaram num tráfico de drogas. Eu não sei de onde apareceram as drogas. Eu não estava bêbado. Eu não cheguei a falar nada com os policiais, alguém que estava com a gente falou "olha o leite", mas eu não sei ao certo quem. Não conhecia os policiais anteriormente. Não cheguei a ver droga nenhuma. Desconheço sobre o veículo. Já fui processado por lesão corporal. Não sei por que fui levado para a delegacia. Não cheguei a ver droga nenhuma. Eu não fui interrogado. Tenho três filhos registrados, tenho um enteado. Quando eu fui preso, só tinha dois filhos.

Não fui usuário de droga. Tomamos umas doze latinhas de cerveja. Os policiais invadiram a residência, sem autorização nenhuma. Desconheço a expressão "leite" no jargão criminal. Não me recordo quem falou "olha o leite". O delegado não me mostrou nada na delegacia. Fui direto po xadrez, só me levaram para assinar.

Ocorre, porém, que os argumentos do acusado não encontraram respaldo nas demais provas dos autos, motivo pelo qual, não convenceu. O réu não apresentou qualquer versão plausível para sua prisão. Limitou-se a dizer o que todos dizem quando são surpreendidos em poder ou nas proximidades de grande quantidade de drogas, ou seja, que nada de ilícito estava fazendo quando foi abordado e detido, de modo que não se pode acreditar que os policiais resolvessem, do nada, acusá-lo da prática de um crime de tamanha gravidade, não tivesse efetivamente participação no crime em voga. Ainda mais quando as partes são desconhecidas, como no presente caso e não há uma evidência sequer a revelar que a acusação pudesse ter por fundamento apenas

vingança ou outro motivo qualquer.

Não há como se acreditar que os policiais resolvessem amealhar entorpecentes e dinheiro, em local diverso, colocando-os a disposição dos autos e da Justiça, apenas para acusar o réu da prática do tráfico de drogas, no afã de vê-lo condenado. Tanto que o próprio réu, em seu interrogatório, afirmou que não conhecia os policiais.

Desta forma, não se tem nos autos, um indício sequer que pudesse evidenciar que toda a prova acusatória tivesse sido produzida com a finalidade única de prejudicar o réu ou mesmo acusá-lo falsamente. Ainda mais quando as partes são desconhecidas, como no presente caso.

É certo que a quantidade da droga por si só, não é suficiente a caracterizar o crime de tráfico. No entanto, o montante e variedade de drogas apreendidas em poder do réu, não deixam dúvidas que serviam para o tráfico de drogas, eis que a quantidade apreendida, na circunstância, mostra-se absolutamente incompatível com o uso próprio.

Além disso, as demais circunstâncias dos autos, tais como, a atitude suspeita do réu ao avistar os policiais, o local conhecido como ponto de drogas, sua abordagem e a grande quantidade de drogas encontradas, somado ao relato firme e seguro por parte dos policiais, não deixam dúvidas acerca da traficância.

Tanto é assim que os policiais militares responsáveis pela prisão do réu, Rafael Rodrigues dos Santos e Andre Luiz Moreira, declararam de forma firme, segura e em uma só voz que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, onde há ponto de droga conhecido, quando avistamos o réu e optamos pela abordagem. Em poder dele nada foi encontrado, porém, ao lado de onde ele estava sentado, havia um buraco na entrada da casa em que ele estava sentado, que era a casa dele, foi encontrada uma sacola com drogas. Quando o réu nos viu, ele se assustou, mostrou-se incomodado, foi o que ensejou a abordagem. Debaixo de um carro que estava de frente dele foi encontrada uma porchete contendo mais drogas. O réu negou a posse das drogas. As pessoas dentro da residência saíram e indagaram o que estava acontecendo, quando falamos sobre a prisão e drogas. Não me recordo se o réu estava sozinho ou se tinham outras pessoas com ele. Reconhecemos o réu e não os conhecíamos anteriormente. O réu autorizou a entrada na casa dele, porque ele foi lá buscar os documentos dele. Nós entramos na residência, no corredor, pegamos os documentos e saímos não houve vistoria no interior da residência do réu. Não conheciam o réu anteriormente.

Os policiais narraram com segurança e precisão como se deu a prisão do acusado, relatando todos os detalhes, desde patrulhamento de rotina, a atitude suspeita do réu ao chutar uma pochete para debaixo de um veículo, sua abordagem, o encontro de parte das drogas numa sacola que se encontrava num buraco de um muro e o encontro do restante das drogas e dinheiro dentro da pochete.

Mister se faz, neste momento, dizer que o testemunho dos policiais deve ser valorado como de qualquer outra pessoa, não havendo motivo para de pronto depreciá-lo.

Há muito já se encontra superado o entendimento de que a fala policial não se prestaria como elemento probatório.

No sentido já se manifestou o STF, quando do julgamento do HC 76.557-RJ, 2ªT., rel. Carlos Velloso, 04.08.1998: "O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento."

E ainda: "Como servidores públicos que são, os agentes policiais têm, no exercício de suas funções, a presunção juris tantum de que agem escorreitamente, não estando impedidos de depor sobre os atos de ofício de cuja fase policial tenham participado" (TJ/SP, Ap. 287.216-3, 3ª C., rel. Segurado Braz, 27.01.00).

Além disso, o depoimento dos policiais foi tranquilo, harmonioso e revelou sincronia lógica. Narraram a situação com firmeza, descrevendo as diligências sem qualquer mácula ou eiva de vício a contaminar a prova.

Não houve contradição na parte substancial do que disseram na fase policial e em Juízo e eventuais discrepâncias existentes em seus depoimentos são normais aos

relatos prestados por qualquer ser humano, e em nada abalam a condenação. Tanto é assim que a jurisprudência afirma: "As pequenas contradições decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas pelas condições em que a prova é realizada. O testemunho demasiado perfeito, esse, sim é que deve gerar desconfiança" (TACRIM-SP-AP- Rel. Nelson da Fonseca - JUTACRIM-SP 67/311). Tal a circunstância dos autos. A fala das testemunhas mostrou-se coerente, repita-se e firme desde a fase inquisitiva, narrando com clareza o discorrer dos fatos. Em que pesem, pois, os argumentos da defesa, vejo nos autos que todas as circunstâncias apontam em sentido contrário.

Temos ainda o depoimento da testemunha de defesa Elizabel da Cruz que declarou em juízo que sou companheira dele há dois anos, mas nos conhecemos há oito anos. Eu estava na casa da vizinha e foram me chamar. Os policiais estavam dentro de casa, não quiseram falar comigo, estava uma bagunça dentro de casa. Depois, fui para a delegacia, onde não me passaram nenhum tipo de informação. O Jeferson não usa e nem vende drogas. Ele estava no portão de casa com uns amigos dele. O policial não me deu atenção. Os policiais quebraram tudo em casa. Isso aconteceu em um sábado de tarde. Jeferson trabalhava de fazer fachada, não é exatamente pedreiro. Foi preso uma vez por um negócio de Maria da Penha. Os policiais não tinham motivo nenhum para prejudicá-lo. Não sei se alguém queria prejudicá-lo. Nunca tinha visto aqueles policiais.

Por fim, a testemunha Mauricio de Oliveira, declarou que sou amigo do réu. É uma mentira tão grande, é tudo mentira. Ele estava bêbado. Estávamos sentados na calçada bebendo cerveja. O Jeferson é brincalhão e falou "ó o leite" para os policiais. Daí, os policiais voltaram e entraram no meu corredor. Eles entraram forçando na residência dele, que está alugando. Ele estava muito bêbado. Falei que não pode entrar para os policiais porque não têm permissão e falaram que o Jeferson autorizou, mas ele estava bêbado demais. Ele estava muito embriagado. Não houve droga, foi inventada. Os policiais não falaram nada. É a primeira vez que isso aconteceu no meu quintal, onde alugo quartos. Eu estava sentado na calçada com Amanda, a esposa dele e mais um rapaz. Eu não estava embriagado. Apenas o réu foi levado para a delegacia. Os policiais são os mesmos que vem sempre e eles ficam com raiva de não pegar nada e, de vez em quando, pegam um bode expiatório. Eu não mexo com droga, o réu já mexeu com droga, há muitos anos, quando morava em outro lugar. Ele nunca foi preso porque era inteligente, mas não é pessoa ruim e, nesse dia, não estava com drogas.

Ocorre, porém, que os depoimentos das testemunhas de defesa, ao contrário do que ocorre com os depoimentos dos policiais, não podem ser considerados imparciais, já que, amigas e próximas do réu, outra não poderia ser a conduta delas senão tentar, de todas as formas, inocentá-lo de tão grave acusação. Ademais, muitas vezes, mesmo tratando-se de pessoas próximas e ligadas aos agentes, não têm conhecimento acerca da traficância que praticam.

Até porque as contradições existentes entre a fala da testemunha Maurício fragilizam sobremaneira a possibilidade de serem dadas quaisquer credibilidade a elas. Veja que o próprio acusado, contrariando a versão da testemunha, negou que estivesse bêbado, ou que tivesse dito, "olha o leite".

Neste contexto, em vista da grande quantidade de drogas encontradas na proximidade do réu, e ainda o relato seguro e firme por parte dos policiais, resta inexoravelmente comprovado que mantinha substância tóxica para consumo e entrega a terceiros.

Nem se cogite que a ausência de descrição de ato de venda, compra ou qualquer outro que indicasse atividade de mercância, pudesse vir a inocentar o acusado da imputação descrita na denúncia. E isso porque, tratando-se de tipo penal tido como de conteúdo múltiplo ou variado, preencheu o réu um dos núcleos do tipo denunciado, sendo, pois, impossível a absolvição. Para a condenação, na hipótese dos autos, é absolutamente irrelevante não ter o agente, sido surpreendido no ato da venda, bastando que haja indicativos outros, como forma de acondicionamento da droga e respectiva quantidade, a indicar a finalidade do tráfico.

No sentido: "Pretendida a desclassificação do art. 12 para o art. 16 da Lei 6368/76

- Inadmissibilidade - Prova robusta no sentido de tipificar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes - Irrelevante não ter o apelante sido surpreendido no ato da venda - Forma de acondicionamento da droga em invólucros indicativos de fim de mercancia - Recurso não provido. (Ap. 296.182-3, São Paulo, 4ª C., rel. Canelas de Godoy, 25.04.2000, v.u.).

Passo a dosar a pena.

Verificando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, atento dolo normal à espécie.

O acusado é primário sem antecedentes criminais, de maneira que fixo a pena base no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

O valor de cada dia multa será o mínimo legal.

Na hipótese dos autos, forçoso de faz reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei de Tóxicos. E isso porque o acusado primário, sem quaisquer antecedentes, e não há um indício sequer a demonstrar que faça parte de alguma organização criminosa.

Assim, considerando-se a capacidade lesiva de uma das drogas em questão, tratando-se de crack, reduzo a pena base em 1/3 (um terço), perfazendo 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Sobre o tema, já assentou o Colendo Superior Tribunal de Justiça que "O art. 42 da Lei nº 11.343/06 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base, quanto na determinação do grau de redução da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da nova lei de Tóxicos. Na hipótese, à luz do art. 42 da lei 11.343/2006, a natureza da substância entorpecente apreendida - 13 (treze) pedras de crack - justifica a não aplicação do redutor em seu grau máximo, qual seja: 2/3" (5ª T., HC 225.575/ES, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Dje 05/06/2012).

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal, para condenar JEFFERSON BATISTA DA SILVA, como incurso nas penas do artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06, a cumprir, em regime inicialmente aberto, a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Na hipótese específica destes autos, o regime aberto se justifica tendo em vista que o réu é primário, sem qualquer mácula em sua vida, foi solto no curso do processo e compareceu a todos os atos para os quais foi chamado.

De outro giro, não é possível a aplicação de qualquer substituição, porque o escopo do legislador foi beneficiar delitos que não mantêm repercussão na sociedade, o que não é o caso do tráfico de drogas, cujo promovedor deve ser segregado do convívio social. Não se pode perder de vista ainda, que o artigo 33, §4º da Lei de Tóxicos prevê, de forma expressa a vedação da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

É certo que o STF, nos autos do HC 97256/RS, cujo relator foi o Ministro Carlos Ayres Brito, declarou de forma incidental a inconstitucionalidade da vedação em apreço. Mas é certo também que referida decisão foi proferida por maioria apertada (6x4) e reconhecida, apenas na hipótese específica daqueles autos, alcançando tão somente, as partes que ali figuraram.

No mesmo sentido, foi a recente decisão proferida pela 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Apelação nº 0090150-57.2012.8.26.0050, cujo teor passo a descrever: "Como bem colocado pelo Ilustre Desembargador Souza Nery: "inviável a aplicação da pena alternativa. Não só pela própria hediondez do crime, que recomenda maior rigor no escarmento, mas também porque a Lei nº 11.343/06 expressamente veda a benesse aos traficantes, nos precisos termos do que dispõe o seu artigo 44, caput. Tal dispositivo legal foi editado pelos poderes competentes, goza de presunção de constitucionalidade e não parece ofender a Constituição de República de modo franco e direto. Não desconheço

que foi reconhecida a inconstitucionalidade desse dispositivo pelo Excelso Pretório (HC 97.256) no ano de 2010, mas essa decisão foi tomada por maioria apertada (6 x 4) e valeu somente para o processo julgado (incidenter tantum)."

Desta forma, não há qualquer declaração de inconstitucionalidade erga omnes, de maneira que, em cada caso concreto, a vedação imposta pela Lei de Tóxicos, pode ser aplicada e reconhecida.

Em arremate, o condenado é primário, jovem e compareceu aos atos para os quais foi chamado, de maneira que concedo a ele o direito de aguardar o trânsito em julgado desta em liberdade.

Oficie-se à autoridade policial, oportunamente, para incineração do entorpecente apreendido, nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06.

Extraiam-se cópias para apuração do suposto crime de falso testemunho por parte de MAURICIO DE OLIVEIRA, nos termos requeridos pelo Ministério Público.

Concedo ao réu os benefícios da Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado declaro a perda do dinheiro em favor da União.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 11 de agosto de 2022.

EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA